

次のⅠからⅢまでの各【事例】における甲の罪責及び処断刑の範囲について判例の立場に従って検討した上、各【事例】に関する後記アからオまでの各【記述】が正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。ただし、刑種についてははすべて有期拘禁刑を選択し、甲に前科及び刑の減輕事由はないものとする。(改)

【事例】

- Ⅰ. 甲は、コンビニエンスストアでおにぎり1個(時価150円相当)を窃取したが、甲の犯行を目撃して追いかけてきた店員乙に対し、同人に捕まえられるのを免れる目的で、反抗を抑圧するに至らない程度の暴行を加えて加療約1週間を要する傷害を負わせた。
- Ⅱ. 甲は、乙から金品を喝取しようと企て、乙に対し、反抗を抑圧するに至らない程度の暴行を加えて加療約2週間を要する傷害を負わせ、畏怖した同人から現金1万円を喝取した。
- Ⅲ. 甲は、乙から金品を強取しようと企て、無施錠の玄関から同人方に立ち入り、同人所有の現金1万円を窃取し、その直後に帰宅した乙に対し暴行を加えてその反抗を抑圧した上、同人から現金3万円を強取した。

【記述】

- ア. 【事例】Ⅰでは、甲を拘禁刑22年に処することができる。
- イ. 【事例】Ⅱでは、甲を拘禁刑20年に処することができる。
- ウ. 【事例】Ⅲでは、甲を拘禁刑23年に処することができる。
- エ. 処断刑の上限が最も重いのは【事例】Ⅲである。
- オ. 処断刑の上限が最も軽いのは【事例】Ⅱである。

(参照条文) 刑法(改)

(住居侵入)

第130条 正当な理由がないのに、人の住居(中略)に侵入し(中略)た者は、3年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金に処する。

(傷害)

第204条 人の身体を傷害した者は、15年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。

(窃盗)

第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。

(強盗)

第236条 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期拘禁刑に処する。(以下略)

(事後強盗)

第238条 窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。

(強盗致死傷)

第240条 強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の拘禁刑に処(中略)する。

(恐喝)

第249条 人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の拘禁刑に処する。(以下略)

Na209	処断刑						正答率
H21-20	正解	ア	イ	ウ	エ	オ	13%

ア 正しい ★

大判昭 19.2.8。本記述（【事例】Ⅰ）では、まず、乙に傷害を与えた甲に事後強盗罪（238 条）が成立するかを判断する前提として、「暴行……をした」といえるかが問題となる。この点、判例は、同条の「暴行」といえるためには、相手方の反抗を抑圧すべき程度で、財物の取返しや逮捕の行為を抑圧するに足りる程度のものでなければならないとしている。本記述において、甲が乙に対して加えた暴行は、「反抗を抑圧するに至らない程度の暴行」にすぎないので、事後強盗罪は成立しない。次に、甲には、おにぎり 1 個を窃取した時点で窃盗罪（235 条）が、暴行を加えて加療約 1 週間を要する傷害を負わせた時点で傷害罪（204 条）が成立する。そして、窃盗罪と傷害罪は、併合罪（45 条前段）の関係となる。併合罪については、「その最も重い罪について定めた刑の長期にその 2 分の 1 を加えたものを長期とする。」と定められ（47 条本文）、更に、「有期拘禁刑を加重する場合においては 30 年にまで上げることができ」とされている（14 条 2 項）。本記述において、窃盗罪は「10 年以下の拘禁刑」、傷害罪は「15 年以下の拘禁刑」であり、最も重い罪は傷害罪となり（10 条 2 項）、長期の上限は、傷害罪の刑の長期（15 年）にその 2 分の 1 を加えた 22 年 6 月となる。よって、処断刑は 1 月以上 22 年 6 月以下となるので（12 条 1 項、14 条 2 項）、甲を拘禁刑 22 年に処することができる。

イ 誤っている

本記述（【事例】Ⅱ）では、反抗を抑圧するに至らない程度の暴行を加えて、現金を喝取した場合に、恐喝罪（249 条 1 項）と暴行により生じた傷害の関係が問題となる。まず、「恐喝」とは、財物交付に向けて行われる脅迫又は暴行であって、その反抗を抑圧するに至らない程度の行為をいうところ、本記述では、甲は乙に「反抗を抑圧するに至らない程度の暴行を加えて……畏怖した同人から現金 1 万円を喝取した」ので、恐喝罪が成立する。また、甲は、乙に「反抗を抑圧するに至らない程度の暴行を加えて加療約 2 週間を要する傷害を負わせ」たため、傷害罪（204 条）が成立する。そして、恐喝の手段たる暴行で、傷害の結果が生じたという事案において、判例は、恐喝罪と傷害罪との観念的競合（54 条 1 項前段）の関係にあるとしている（最判昭 23.7.29）。観念的競合の場合の処断刑は「その最も重い刑によ」ところ、傷害罪は「15 年以下の拘禁刑」、恐喝罪は「10 年以下の拘禁刑」であり、最も重い罪は傷害罪となり（10 条 2 項）、本記述では刑の長期の上限は、15 年である。

ウ 誤っている ★

最決昭 29.5.27（百選 I 106 事件）。本記述（【事例】Ⅲ）で、甲が無施錠の乙方に立ち入った行為については、管理者乙の意思に反した住居への立入りといえるので、住居侵入罪（130 条前段）が成立する。また、甲が乙方で現金 1 万円を窃取した行為について、窃盗罪（235 条）が成立し、乙に対し暴行を加えてその反抗を抑圧した上、同人から現金 3 万円を強取した行為について、強盗罪（236 条 1 項）が成立する。そして、窃盗罪と強盗罪については、併合罪（45 条前段）の関係にあるが、住居侵入罪と窃盗罪が牽連犯、住居侵入罪と強盗罪も牽連犯（54 条 1 項後段）の関係にある。そこで、この場合には、住居侵入罪が「かすがい」となって、住居侵入罪と窃盗罪と強盗罪の 3 罪が、科刑上一罪の関係（54 条 1 項後段）になる（いわゆる「かすがい理論」、最決昭 29.5.27）。そして、本記述で、住居侵入罪は「3 年以下の拘禁刑」、窃盗罪は「10 年以下の拘禁刑」、強盗罪は「5 年以上の拘禁刑」であり、最も重い罪は強盗罪となり（10 条 2 項）、本記述の刑の長期の上限は 20 年である（12 条 1 項）。

エ 誤っている ★

処断刑の上限が最も重いのは、刑の長期が22年6月となる【事例】Ⅰである（肢ア参照）。

オ 正しい

処断刑の上限が最も軽いのは、刑の長期が15年となる【事例】Ⅱである（肢イ参照）。